

1500715-55.2022.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Arnaldo Luiz Zasso Valderrama

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... sobre a acusação. Negou ter confessado o tráfico aos policiais. Disse ter ido a Assis e quando voltou entrou no quarto para ver se Eduardo estava lá, Aparecida disse que ele havia voltado cedo. Negou presenciar envolvimento do Eduardo com drogas e tráfico, sabe que ele tem passagem. Narrou ser usuário de maconha desde 2016. Negou ter problema com Eduardo e Aparecida, já os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis

Rua Doutor Lycio Brandao de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500715-55.2022.8.26.0047 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500715-55.2022.8.26.0047

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2086456/2022 - DEL.POL.ECHAPORÃ, 23945561 - DEL.POL.ECHAPORÃ, 47/22/217 - DEL.POL.ECHAPORÃ, 2086456 - DEL.POL.ECHAPORÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JÚLIO VÍTOR TAVARES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Arnaldo Luiz Zasso Valderrama

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra Julio Vitor Tavares, qualificado nos autos, por ter, em tese, praticado o delito tipificado no art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006. Narrou que no dia 29 de março de 2022, por volta das 15h30min., na Rua Eugênio Passareli, nº 187, Centro, na cidade de Echaporã, nesta Comarca, Julio guardava e tinha em depósito 27,72g de maconha, 10,71g de crack, e 75,25g de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo apurou-se, Julio pernitoou na casa do

seu colega Eduardo; o adolescente foi apreendido por tráfico na manhã e confessou que estava vendendo drogas para o réu; em diligências realizadas pela polícia militar, o denunciado foi encontrado e confessou informalmente ter deixado entorpecentes na residência da mãe de Eduardo, foram até o local e, com autorização de Aparecida, e encontraram as porções de droga, além de uma balança de precisão. Notificado, o réu apresentou resposta à acusação (fl.186/204).

A denúncia foi recebida em 17/05/2022 (fl.216/217).

Foi feita a oitiva de testemunhas e o interrogatório do réu (fls.234/235).

Em alegações finais o douto membro do Ministério Público pediu a procedência.

Sustentou que: os policiais confirmaram que Aparecida denunciou o filho e Júlio; pela manhã o adolescente foi preso e a tarde, após Júlio retornar à residência de Aparecida, esta acionou a polícia; no local encontraram mais drogas; afirmaram que Júlio confessou a propriedade delas; não há motivos para crer que os policiais quisessem incriminar injustamente o réu; durante a apuração do ato infracional Aparecida narrou os fatos de forma diferente e disse que presenciou a localização de drogas na parte da tarde; nestes autos mudou completamente sua versão; a mídia de fl.241 prova que Aparecida mentiu, pois acionou a polícia duas vezes; as testemunhas devem responder pelo crime de falso testemunho; a pena-base deve ser incrementada pela variedade e tipo de drogas apreendidas; há a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública; não incide a diminuição do art. 33, § 4º, pois o réu já condenado por antecedentes infracionais; o regime prisional deve ser o fechado, sem substituição de pena e com manutenção da prisão preventiva (fls.245/254).

A douta Defesa pediu a absolvição por insuficiência probatória. Aduziu que: a prova oral colhida contrapõe a denúncia e corrobora a versão do acusado, de que não é o dono das drogas; nada de ilícito foi encontrado com ele; acompanhou voluntariamente os policiais até o local dos fatos; Aparecida não afirmou que a droga era de Júlio; o depoimento dela na Delegacia é questionável por ser mãe do adolescente envolvido; nestes autos Aparecida e Eduardo foram arrolados como testemunha, com obrigação de dizer a verdade; extrai-se do depoimento de Aparecida em juízo contradições quanto à propriedade das drogas; há interesse dela em não prejudicar seu filho; Aparecida confessou que foi orientada pelo PM a dizer que as drogas pertenciam a Júlio, para não prejudicar seu filho; é possível que Aparecida tenha se arrependido de ter entregado seu filho aos policiais; pela ligação do Copom Aparecida afirmou ter drogas em sua casa apenas na parte da manhã e só ligou porque foi orientada pelos policiais que afirmaram que iriam lá pegá-lo; ninguém afirmou ter visto o réu com drogas; os entorpecentes foram encontrados na cabeceira da cama de Aparecida; em juízo Eduardo afirmou desconhecer a titularidade dos entorpecentes; em solo policial também era acusado, portanto pode ter mentido; foi Eduardo quem escondeu as drogas; pela manhã os entorpecentes foram encontrados fora da residência, em local apontado por Eduardo, pode ser que as drogas apreendidas a tarde estavam lá desde a apreensão de Eduardo; o PM Leo sempre aborda o réu e há prova de que o ameaçou a fl.233; os depoimentos dos policiais não pode ter valor probatório maior do que de outras testemunhas; subsidiariamente, pediu a desclassificação do delito para o crime do art. 28 da Lei de Drogas; a fixação da pena-base no mínimo legal; o afastamento da agravante do estado de calamidade; o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e do tráfico privilegiado por ser primário de bons antecedentes; o ato infracional mencionado pela acusação não gera reincidência; o cumprimento de pena em regime inicial aberto (fls.259/279).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. A pretensão veiculada nesta ação penal é procedente.

A materialidade do delito de tráfico de drogas ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.01/02), boletim de ocorrência (fls.09/11), auto de exibição e apreensão (fls.12/13) e laudo de pericial (fls.21/23). Extrai-se do laudo que foram periciados substância pulverizada e fragmentos vegetais, com resultado positivo para cocaína e maconha, as quais constam em lista proibitiva no Brasil. A autoria

também é certa e atribuída ao acusado, conforme se extrai da prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Em seu interrogatório Julio negou ser dele a droga. Relatou que fazia três dias que dormia na casa de Eduardo, havia discutido com a vó, ele concordou que deixasse os pertences lá e ficar na casa até alugar uma. Negou saber sobre a acusação. Negou ter confessado o tráfico aos policiais. Disse ter ido a Assis e quando voltou entrou no quarto para ver se Eduardo estava lá, Aparecida disse que ele havia voltado cedo. Negou presenciar envolvimento do Eduardo com drogas e tráfico, sabe que ele tem passagem. Narrou ser usuário de maconha desde 2016. Negou ter problema com Eduardo e Aparecida, já os conheceu há algum tempo. Falou que desde pequeno o policial lhe aborda e ameaça, já prendeu seu tio e mãe. Negou saber o motivo, ele o ameaça pegar e prender, na melhor hora vai forjar. Afirmou ter saído de lá com a bicicleta do Eduardo. Relatou que foi para sua casa, lá os policiais disseram que Eduardo foi preso e deveria trazer a nota dos pertences para provar que não era roubado. Negou ser sua a droga na casa, tê-la visto e saber qual era. Disse conhecer a mãe do Eduardo de vista. Ressaltou que Eduardo era usuário de maconha. Confirmou que perguntou para Aparecida onde Eduardo estava, o depoente foi para o quarto, ligou ventilador e o videogame, depois sentiu fome e foi para casa de sua mãe. Narrou que ficou no quarto do Eduardo. Negou ter bom relacionamento com o policial Leo, ele sempre o abordava e fazia passar vergonha. Acrescentou que quando foi levado até Marília o policial falou à Aparecida para dizer que a droga era do depoente, senão o filho dela seria preso. Disse crer que Aparecida e Eduardo não tem fonte de renda. Falou que às vezes trabalhava como servente de pedreiro e na roça, não tem renda mensal fixa, quando precisa seu avô lhe ajuda. Informou foi a Assis tentar alugar uma casa e entregar currículos.

A testemunha Aparecida afirmou que foi limpar o seu quarto e achou a droga, perguntou ao filho Eduardo e ele negou saber a procedência. Relatou que chamou a polícia e seu filho negou saber de quem era. Mencionou que o filho deu pouso para o réu porque ele tinha discutido com a família. Declarou que quando a polícia chegou a droga estava num matinho, o policial Leo pediu para falar que a droga era do Júlio, para não prejudicar. Salientou que o Júlio estava em Assis e não voltou para casa. Ressaltou que foi a única vez que policial apreendeu droga em sua casa. Negou saber a quanto tempo o filho e o réu eram amigos. Frisou que o réu ficou três dias em sua casa. Contou que o policial Leo prendeu Eduardo. Negou que seu filho tenha falado que a droga era do Júlio. Disse ter pensado que era do Júlio, pois ele dormiu em sua casa. Enfatizou que o Leo pediu para a depoente dizer que a droga era do réu. Acrescentou que a polícia foi em sua casa de manhã e o Júlio foi detido a tarde. Disse que policiais pegaram o Júlio na frente da casa da mãe dele e estava com a bicicleta. Negou ter sido apreendida droga em sua casa na parte da tarde. Esclareceu que o Júlio dormia numa caminha no quarto do Eduardo. Narrou que a droga estava na cama da depoente, em outro quarto.

A testemunha Eduardo negou saber dos fatos. Relatou que eles pegaram o réu a tarde e o depoente nem sabia. Mencionou que o réu dormia em sua casa, pois tinha discutido com a família. Declarou que sua mãe achou maconha e crack na sua casa. Negou saber de quem era. Informou que tirou essa droga de sua casa para não lhe prejudicar. Negou ter como explicar como a droga apareceu em sua casa. Negou ter dito aos policiais que a droga era do Júlio, foi sua mãe quem disse isso. Disse que contou na delegacia que a droga era do Júlio porque a mãe falou. Narrou que conhece o réu há muito tempo e ele estava em sua casa há 3 dias. Ressaltou saber que o réu era usuário de maconha. Salientou que hoje mesmo os policiais lhe encararam. Negou saber se o réu era prejudicado. Comentou que segundo a mãe o policial disse para ela falar que a droga era do Júlio senão ia lhe prejudicar. Afirmou que mora com a irmã. Negou saber por que a mãe lhe denunciou.

A testemunha Fábio afirmou que a mãe falou que tinha drogas em casa e no momento da apreensão Eduardo falou que vendia drogas para Júlio e este estaria em Assis buscar mais entorpecentes para venda. Relatou que no período da tarde a genitora de Eduardo novamente chamou a polícia denunciando que Júlio havia retornado de Assis e estaria em sua residência. Mencionou que ela lhe falou que Júlio havia acabado de sair com bicicleta, ele foi abordado nas imediações e com ele nada foi localizado.

Declarou que ao ser questionado se tinha ido a Assis buscar drogas ele confessou que foi comprar drogas e acondicionou na cabeceira da cama onde estava dormindo. Disse que voltou na casa e acharam no local informado 8 porções de maconha, 16 de crack e 36 pinos de cocaína. Falou que Júlio confessou que a droga era dele. Esclareceu que na primeira ligação de Aparecida o filho escutou, tirou a droga de casa e escondeu num terreno ao lado da residência. Contou que o rapaz admitiu isso e os levou até o terreno, onde havia 3 tabletes de maconha e crack. Negou conhecer o Eduardo e o Júlio, pois o depoente era interino em Echaporã. Afirmou que o cabo Leo conhecia o Júlio. Relatou que na segunda vez que Aparecida ligou o Júlio ainda estava lá. Mencionou que a droga foi achada no quarto do Eduardo, na cama dele, havia pertences do Júlio nesse local. Negou ter dúvida de que essa cama era do Eduardo, quando o apreendeu pela manhã fez buscas no quarto para ver se tinha mais drogas e Eduardo identificou o quarto como dele. Salientou que Eduardo confirmou que a droga era do Júlio e ele trabalhava para o réu vendendo drogas na casa dele. Declarou que só entraram na residência na parte da manhã, à tarde fez contato com Aparecida na parte externa da casa e depois foram atrás de Júlio. Contou que o réu foi abordado na frente de uma residência. Negou que ele tenha empreendido fuga, não estava com nada ilícito consigo. Narrou que a revista pessoal foi porque de manhã o Eduardo disse que a droga era do Júlio e estava vendendo drogas para o réu.

Tais informações foram confirmadas pelo policial Leo. Afirmou que a testemunha ligou à polícia falando que o filho e o réu estavam vendendo drogas, sabia que era verdade porque não foi a primeira vez que ela o denunciou. Relatou que Eduardo lhe disse que Júlio foi na Progresso comprar drogas e não foi junto por não ter acordado. Mencionou que levaram ele para registrar a ocorrência e a orientaram a ligar se ele retornasse. Declarou que Aparecida ligou para avisar e ela disse que ele entrou na casa, foi ao quarto e saiu com a bicicleta. Salientou que encontrou o réu na frente da residência. Disse que a mãe do Eduardo falou que o réu chegou lá há quatro dias, estavam mesmo vendendo drogas. Contou que o réu negou estar morando na casa. Negou ter encontrado algo de ilícito com o réu. Falou que pediram a ele para voltar para a casa, nisso o réu confessou que havia drogas e era dele. Salientou que na residência achou na cabeceira da cama pinos de cocaína. Frisou que nesse quarto dormiam Júlio e Eduardo. Esclareceu que na parte da manhã quando a mãe ligou Eduardo tirou a droga e escondeu, depois ele mostrou que estava num terreno perto da casa dele, havia cocaína e uns pedaços de maconha. Narrou que sempre tinha denúncias de Júlio, a família já tinha procurado porque ele tinha quebrado coisas na casa e não o queriam lá, vinte dias antes da ocorrência ele fugiu do depoente e pulou várias casas. Acrescentou que segundo o réu nesse dia ele estava com entorpecente. Confirmou que Aparecida fez duas ligações para o Copom, uma pela manhã e outra pela tarde. Afirmou que essa ligação fica registrada no Copom Bauru. Relatou que conhece Júlio há bastante tempo, desde que foi preso com Cristiano por um roubo. Mencionou que havia várias denúncias de tráfico envolvendo o réu. Salientou que o réu disse algumas vezes ser usuário de maconha. Declarou que já abordou o réu algumas vezes, não sabe dizer quem estava presente. Narrou que realizava buscas pessoais. Negou ter desavença com Júlio e tê-lo ameaçado. Negou ter dito à Aparecida para ela falar que a droga era do Júlio.

Pois bem. Ressalto que o tráfico de entorpecentes se configura com a prática de várias condutas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e, como tipo misto alternativo que é, a incidência em qualquer delas justifica a violação do bem jurídico protegido. Desnecessário, portanto, o flagrante do momento da efetiva tradição ou venda do entorpecente para incidência do tipo penal. É dizer, as condutas periféricas à efetiva comercialização, como trazer consigo, guardar, transportar ou manter em depósito, por exemplo, são suficientes à transgressão do ilícito penal.

Segundo o art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, a classificação da conduta em porte para uso próprio (ou tráfico de drogas, a contrário sensu) se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Os fatos foram comprovados pela prova oral. Os policiais narraram que Aparecida,

genitora do adolescente Eduardo, encontrou drogas em sua residência e acionou a polícia militar. Eduardo, que a princípio escondeu as drogas e negou sua existência, acabou mostrando aos policiais onde elas estavam. Ele confessou que eram de Júlio e que vendia para o réu. Falaram que Júlio estava pernoitando na casa de Eduardo há 3 dias e as drogas estavam no quarto onde dormiam.

No mesmo dia, à tarde, Júlio retornou a casa de Eduardo e Aparecida, ela acionou novamente a polícia militar, por orientação dos policiais que a atenderam pela manhã. Quando a viatura chegou Júlio já tinha saído. Os militares localizaram o acusado e o abordaram, após ser questionado confessou ter deixado entorpecentes na residência de Aparecida e indicou a cabeceira da cama. Eles voltaram à casa de Aparecida onde realizaram busca no quarto ocupado por Júlio e Eduardo, na cabeceira da cama encontraram mais porções de drogas: maconha, crack e cocaína. A diligência foi acompanhada por Aparecida, que presenciou a apreensão das drogas.

Ressalto que os depoimentos dos policiais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais, sendo totalmente descabido o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a Juízo com o intuito mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas que teriam ensejado a prisão do réu.

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de se tratar de Agentes Estatais incumbidos do dever da repressão penal (Rel. Carlos Bueno, RJTACRIM 49/263).

Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais ou guardas civis. Não há elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar gratuitamente o réu e não se pode desmerecer a fala só por pertencerem aos quadros da Polícia. Foram submetidos ao contraditório como qualquer testemunha. Seria contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção da criminalidade e lhes negar esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta de suas atividades.

Guilherme de Souza Nucci leciona sobre a validade dos depoimentos dos policiais: "(...) preceitua o art. 202 do CPP que 'toda pessoa pode ser testemunha', logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho" (in Leis Penais e Processuais Penais comentadas, 2ª ed., São Paulo: RT, 2007, p.323).

Nesse sentido, por sinal, a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF, HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j.05.09.06 DJU 16.02.07, destaquei).

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p.39.846, destaquei).

Na mesma linha é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. EXAME DE CORPO DE DELITO. ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE QUANDO PRESENTES PROVAS OUTRAS NOS AUTOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PRECEDENTES DO STJ E STF. ALEGADA NULIDADE INEXISTENTE. [...]. CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS OFENDIDOS. VALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOBSERVÂNCIA. [...] 3. Embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido - no caso os policiais, representado o Estado Administrador/sujeito passivo do crime -, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento. 4. Nesse contexto, e com maior razão, esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. 5. Ordem denegada. (STJ HC 177.980/BA 5ª T. Rel. Min. Jorge Mussi j. 28.06.2011, destaquei).

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ARTS. 33, DA LEI N.º 11.343/06, 304 E 333, DO CÓDIGO PENAL. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. ILEGALIDADE DA DOSIMETRIA DAS PENAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. [...]" (STJ HC 149.540/SP, 5ª T. Rel. Min. Laurita Vaz j. 12.04.2011, DJU 04.05.2011, destaquei).

"O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos". (STJ AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013, destaquei).

Ressalto que os policiais foram coerentes sempre que ouvidos e seus relatos harmônicos entre si e estão em consonância com as declarações de Aparecida e Eduardo, tanto em solo policial como durante a apuração do ato infracional conexo (fls.119/125). Aliás, as contradições constatadas nos depoimentos dessas testemunhas só deixam claro que mentiram em juízo.

Senão vejamos. Eduardo disse na Delegacia que no dia anterior Júlio confessou que guardava drogas na casa. Ouvido em apresentação no processo de ato infracional, o adolescente deu versão semelhante: que viu Júlio trazer a droga para sua casa um dia antes. Mas agora negou saber da existência dos entorpecentes. Questionado sobre a divergência, Eduardo não soube dar qualquer explicação, alegando que só disse que as drogas eram de Júlio porque sua mãe havia dito isso. Ora, foi sua mãe quem falou ou foi Júlio?

Em solo policial, no dia dos fatos, Aparecida afirmou que pela manhã encontrou drogas no quarto do filho, onde pernoitava Júlio. Ouvida como testemunha no auto de prisão em flagrante (fl.06) e em declarações no auto de apreensão do adolescente (fl.31), Aparecida asseverou que o filho disse que as drogas eram de Júlio, mas ele estava ajudando a vender. Na parte da tarde, quando Júlio voltou a sua residência, ela ligou à polícia novamente. Após localizarem o acusado os milicianos o conduziram até a residência dela, onde realizaram buscas no quarto que ele ficava e localizaram mais entorpecentes, as buscas foram acompanhadas por Aparecida. Tais relatos guardam estreita semelhança com o depoimento dela nos autos de apuração do ato infracional praticado pelo filho e com o depoimento do adolescente,

tanto em solo policial como na referida audiência.

Todavia, ouvidos em Juízo nestes autos, Aparecida e Eduardo mudaram totalmente suas versões e contaram história parecida com o que foi narrado pelo réu, porém foram extremamente contraditórios deixando clarividente que mentiram.

Aparecida em Juízo negou que o filho tenha lhe dito que as drogas pertenciam a Júlio, mas contou duas histórias diferentes sobre a circunstância. Primeiro disse que o policial Leo a mandou dizer que as drogas eram de Júlio, para livrar seu filho das acusações, mas depois alegou que presumiu que as drogas fossem do acusado porque ele estava pernoitando na residência.

A testemunha também foi contraditória quanto ao local em que encontrou as drogas pela manhã. Disse que os entorpecentes estavam em sua cama, mas questionada pelo Ministério Público explicou que Júlio dormia na cama onde as drogas foram encontradas, e em várias oportunidades ficou esclarecido que ele dormia no quarto de Eduardo. Não bastasse, é pouco crível que o acusado dormisse na cama de Aparecida ou mesmo que alguém deixaria drogas ali.

Aparecida também mentiu em Juízo quando disse que Júlio não retornou a sua residência a tarde e que ela não acionou a polícia novamente. As fls.240/241 foi juntada cópia da gravação da ligação feita por Aparecida ao Copom quando Júlio chegou na sua casa. Ademais, ele mesmo confirmou isso em seu interrogatório afirmando que foi para o quarto, ligou o ventilador e o videogame, mas logo saiu de casa e foi para a casa da mãe dele.

Embora Aparecida tenha negado a apreensão de mais drogas na parte da tarde, quando ouvida tanto na delegacia como no processo de apuração de ato infracional, ela confirmou que acompanhou a diligência e presenciou quando os policiais encontraram os entorpecentes. Tais relatos vão ao encontro da fala dos policiais deixando claro que ela mentiu em Juízo.

Também é improvável que o policial Leo tenha orientado Aparecida a dizer que as drogas eram de Júlio. A uma porque a testemunha e o réu divergiram sobre o momento da orientação, Aparecida disse que isso aconteceu quando encontraram as drogas pela manhã, mas Júlio disse que foi no caminho para a Delegacia de Marília, que eles estavam todos na mesma viatura e o policial teria dito a ela para o incriminar. A duas porque não teria sentido o policial dizer isso na frente do acusado. Ficou evidente que testemunha e réu mentiram sobre isso também.

A combativa Advogada sustentou que Aparecida disse que as drogas eram de Júlio para não prejudicar o filho Eduardo. Ocorre que ela mesma o denunciou à polícia e essa não foi a primeira vez que fez isso. Nos seus relatos em solo policial não demonstrou qualquer arrependimento da atitude tomada. Contou que achava que Eduardo e Júlio cometiam o crime pela movimentação estranha em sua casa depois que Júlio passou a morar lá e já tinha avisado o filho que faria a denúncia caso soubesse de novo envolvimento dele com o tráfico. Não tem lógica alguma afirmar que ela incriminou injustamente Júlio, a pedido do policial Leo, para não prejudicar seu filho, mas ao mesmo tempo revelou à polícia que o filho Eduardo estava traficando. No interrogatório o requerido Júlio disse ter sido enganado pelos policiais para que fosse à casa de Aparecida, asseverando que eles disseram que precisava apresentar as notas fiscais de sua televisão e videogame e que algumas pessoas presenciaram tais fatos, mas estranhamente não arrolou nenhuma testemunha que confirmasse isso.

Malgrado os esforços da zelosa Defesa, não é possível supor que as drogas encontradas a tarde poderiam estar no quarto desde a apreensão pela manhã. Fábio afirmou que a droga foi achada na cama do quarto do Eduardo e lá havia pertences do Júlio. Ressaltou que quando apreendeu o adolescente pela manhã fez buscas no quarto para ver se tinha mais drogas e o menor identificou o local como dele. Isso prova dois fatos: 1) os policiais já tinham feito buscas naquele local onde estava a droga pela manhã e não reportaram a localização de outros entorpecentes; 2) o não foi o responsável pela droga apreendida a tarde, pois desde a manhã estava apreendido.

O fato de Aparecida ter dito ao policial do Copom que não havia drogas no local à tarde, pois os policiais militares já tinham as apreendido pela manhã, não prova a inexistência de entorpecentes. Aparecida quando ligou para o Copom ainda não sabia

que Júlio tinha trazido mais drogas para casa, só tomou conhecimento após a chegada dos policiais e a realização de busca.

Vale destacar que o próprio réu admitiu ter ingressado no quarto de Eduardo na parte da tarde, onde depois foi achada a droga. Eduardo estava impossibilitado fisicamente de tê-la colocado lá e certamente não foi Aparecida quem fez, caso contrário não teria chamado a polícia.

O fato de o policial Leo abordar frequentemente o réu não quer dizer que o persegue. Júlio já é conhecido dos meios policiais por envolvimento com o tráfico de drogas desde a adolescência, a abordagem preventiva é lícita e não implica necessariamente em perseguição. Mormente porque não foram trazidos elementos de convicção aptos a comprovar a arbitrariedade das abordagens pretéritas, ou mesmo que estas ocorreram ao arrepio da lei.

A suposta ameaça juntada a fl.233 não prova que o flagrante tenha sido forjado. Ainda que se cogite existir animosidade entre o policial e o réu, não há motivo para que o outro militar, que apresentou a ocorrência e deu relato idêntico ao de Leo, tenha mentido para incriminar Júlio, até porque nem conhecia o réu e trabalhava apenas interinamente em Echaporã.

Embora Júlio e seu comparsa Eduardo não tenham sido flagrados vendendo drogas a terceiros é evidente que a destinação era a venda. Isso porque segundo o auto de exibição e apreensão de fls.12/13 foram localizadas 8 porções de maconha (27,7g), 16 pedras de crack (10,71g) e 36 microtubos de cocaína (75,25g), cuja quantidade, variedade e forma de acondicionamento evidenciam a traficância. Também apreenderam balança de precisão, petrecho tipicamente usado por traficantes para pesar as drogas que serão comercializadas.

Com a devida vênia ao entendimento da combativa Defensora, é inviável a desclassificação da conduta. O réu sequer alegou em seu interrogatório que as drogas eram para seu consumo pessoal. Na verdade, ele negou a propriedade de todas as porções apreendidas. Ainda que não fosse, o fato de o requerido ser usuário de entorpecentes não afasta o crime de tráfico de drogas. Isso porque ele narrou ser usuário de maconha, porém também foram apreendidas porções de crack e cocaína, e ele mesmo afirmou que na época não trabalhava. Assim, não é crível que tivesse condições financeiras de comprar toda a droga apreendida apenas para seu consumo pessoal.

Destarte, o conjunto probatório é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico, não sendo o caso de aplicação do princípio in dubio pro reo.

Respeitado o sistema trifásico, estabelecido na Constituição Federal, e considerando as diretrizes estipuladas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, passo a dosagem das penas, eis que não milita em favor do acusado qualquer dirimente: Consoante a inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena (STF, HC 127241/SP, rel. Min. Dias Toffoli, julgado 04-08-2015, STF, RHC 117489/MS, Rel. Min. Rosa Weber, julgado 18-06-2013) e constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal (STF, RHC 122598, Rel. Min. Teori Zavaski, julgado em 14-10-14). A culpabilidade, entendida como índice de reprovabilidade da conduta, é de elevadíssima intensidade porque apreendidas várias porções de crack (16 pedras), droga de extrema nocividade em razão de seu alto poder de viciar seus usuários, a exigir certo incremento da basilar, nos termos do artigo 42 da Lei nº. 11.343/06, sem contar a apreensão de maconha e cocaína (a indicar variedade de droga). É primário e não ostenta maus antecedentes (fls.32/34). Não há informação acerca de sua conduta social e personalidade. Os motivos e circunstâncias do crime foram inerentes ao tipo penal. Os motivos e circunstâncias foram inerentes ao tipo. Na primeira fase, atento a tais circunstâncias, fixo a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase reconheço a agravante do art. 61, II, "j", do Código Penal, eis que o crime foi cometido durante o estado de calamidade pública causado pela pandemia de Coronavírus. Reconhecidamente, a sociedade encontra-se vulnerável no âmbito da saúde e, também, no aspecto psicossocial, pois o isolamento e as restrições

impostas à circulação de pessoas têm causado conflitos psicológicos que levam, muitas vezes, à utilização de produtos químicos, incluindo entorpecentes. Também há notícias de que policiais tem ficado doentes por causa do Coronavírus, de modo que não é absurdo concluir que essa pandemia pode afetar a fiscalização de crimes como o tráfico. Esta agravante já foi aplicada em no julgamento de um traficante pelo C. STJ:

“(...) Impende destacar que os autuados foram presos em flagrante durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, circunstância que eleva a reprovabilidade de suas condutas, eis que previsto como agravante genérica (art. 61-II, 'j', do CP). Veja-se que nem mesmo o alto risco de contágio foi motivo suficiente a ser ponderado pelos indiciados a fim de dissuadi-los do intento deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que aumentaram os índices de disseminação do vírus COVID-19 a toda a população do Município, colocando em risco a saúde pública” (STJ, HC 584871/SP, Min, Nefi Cordeiro, j. em 04.06.2020, destaquei).

Além disso, como bem destacou o Exmo. Des. Edison Brandão, “se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência” (TJSP, Apelação nº 1509419-67.2020.8.26.0228, 4ª Câmara de Direito Criminal, j.26.01.2021).

Por outro lado, o réu era menor de 21 anos na data dos fatos e faz jus à atenuante da menoridade relativa. Compenso uma pela outra e mantenho a pena no mesmo patamar. Na terceira fase não há causas de aumento e nem de diminuição da pena. Não deve ser aplicada a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, levando-se em conta que, apesar de não existir outra condenação anterior aos fatos, o requerido já foi condenado por tráfico de drogas quando menor de idade (fls.181/185). Tudo a indicar que o acusado fazia do tráfico o meio de vida desde longa data.

Cumpra destacar que o ato infracional, embora não configure maus antecedentes ou sirva para valorização negativa da personalidade e conduta social do agente, é elemento apto a demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas, afastando-se, desse modo, a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ante o não preenchimento de todos os seus requisitos. Nesse sentido, aliás, é o entendimento do C. STJ:

“O registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes” (Habeas Corpus nº 435.685/SP (2018/0024647-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Ribeiro Dantas. DJe 11.04.2018, destaquei).

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 3. A existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RESp 1560667/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017, destaquei).

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI

11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PELA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) II - No tocante à consideração de atos infracionais anteriores na dosimetria da pena, esta Corte é uníssona no sentido de que não podem ser sopesados na apuração de maus antecedentes para elevar a pena-base, tampouco para induzir a reincidência. Entretanto, este Tribunal tem evoluído, entendendo que os antecedentes infracionais podem indicar uma inclinação do agente a práticas delitivas, sendo inclusive, fundamento idôneo para manutenção da segregação cautelar. Considerando que um dos requisitos para concessão da benesse é o agente não se dedicar a atividades criminosas, é certo que o envolvimento do paciente quando menor em atos infracionais, inclusive relacionados ao crime de tráfico, é elemento idôneo a afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demonstra uma propensão do agente a práticas criminosas. (...) (Habeas Corpus nº 546.923/SP (2019/0349065-0), 5ª Turma do STJ, Rel. Leopoldo de Arruda Raposo. j. 10.12.2019, DJe 17.12.2019, destaquei).

“(...) a existência de atos infracionais cometidos anteriormente pelo paciente, que servem para demonstrar a periculosidade do agente e sua propensão ao cometimento de crimes” (STJ, Habeas Corpus nº 538.171/SP (2019/0302012-3), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 03.12.2019, DJe 11.12.2019).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO DEFINITIVA PELO MESMO DELITO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. CAUSA DE AUMENTO. INFRAÇÃO COMETIDA NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO HOSPITALAR. INCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. 3. A Terceira Seção pacificou entendimento no sentido de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (EResp 1.431.091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 01.02.2017). 3 4. O histórico de envolvimento do agente na prática de atos infracionais, quando menor, sobretudo quando relacionados ao crime de tráfico de drogas, justificam a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas. (...) (Habeas Corpus nº 510.588/DF (2019/0139105-5), 5ª Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. j. 21.11.2019, DJe 05.12.2019, destaquei).

Tal entendimento está consolidado de forma pacífica na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, poderia citar dezenas de julgados nesse mesmo sentido. O entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não destoa deste entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Materialidade e autoria sobejamente demonstradas – Condenação bem lançada – Pleito defensivo que se restringe à pena e ao regime prisional estipulados – Aplicação do redutor aludido no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 – Desacolhimento – Circunstâncias da apreensão que revela aprofundado envolvimento do réu com atividades criminosas – Atos infracionais que, malgrado não se prestem para recrudescer a básica, podem ser invocados para obstar a aludida

minorante - Precedente do STJ - Regime fechado adequado à gravidade concreta dos fatos - Tráfico de maconha e cocaína, estupefaciente este altamente nocivo - Quantidade de drogas com aptidão para atingir diversas dezenas de usuários Substituição da pena defesa (art. 44, I, do CP) - Sentença irreparável - Recurso desprovido. (TJSP, apelação nº 1513738-30.2019.8.26.0320, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Camilo Léllis, j.29/09/2020, destaquei).

Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06). Preliminar inconsistente. Alegada majoração da pena por prática de atos infracionais. Inocorrência. Circunstância, ademais, sanável por esta via, se ocorrente. Ausência de prejuízo. Fundo. Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade das drogas que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policial Militar. Versão exculpatória inverossímil. Necessidade condenatória imperiosa. Responsabilização inevitável. Apenamento criterioso. Exasperação da base adequada. Redução por atenuantes aplicada. Inaplicabilidade do art. 33, § 4º. Acusado que admite a traficância há mais de 2 anos, desde adolescência. Apreensão de narcóticos variados que demonstram envolvimento na criminalidade, ademais. Habitualidade evidenciada. Regime inicial fechado único possível. Apelo improvido, rejeitada a preliminar. (Apelação Criminal nº 1500194-29.2019.8.26.0302, 4ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. Luis Soares de Mello. j. 12.11.2019, Publ. 14.11.2019, destaquei).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 - RECURSO DEFENSIVO BUSCANDO A APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA REFERIDA LEI, A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO, A DETRAÇÃO PENAL E A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR - (...) NA TERCEIRA FASE, AFASTAMENTO JUSTIFICADO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA REFERIDA LEI. A CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENHIDOS, A AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LÍCITAS, O RELATO DOS POLICIAIS E O REGISTRO DA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS, DENOTAM A DEDICAÇÃO DO ACUSADO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS, OBSTANDO, ASSIM, A CONCESSÃO DO REFERIDO REDUTOR. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL. NÃO CABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. (Apelação nº 0001324-28.2016.8.26.0628, 8ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. Ely Amioka. j. 06.12.2018, Publ. 07.12.2018, destaquei).

Assim, muito embora os atos infracionais não sirvam como maus antecedentes, o fato é que Júlio não é um novato no tráfico de drogas. Tudo indica que já se dedica a isso há muito tempo e faz da traficância seu modo de vida. Seria absolutamente desproporcional dar a ele o mesmo tratamento de uma pessoa que está traficando pela primeira vez.

Assim, atinge a pena o montante de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada qual no mínimo legal, em face da renda informada, valor que deverá ser atualizado até o efetivo pagamento, de acordo com o art. 49, caput, e § 2º c/c o art. 60, caput, ambos do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, ex vi dos antecedentes infracionais do réu, já condenado por tráfico de drogas, da quantidade e variedade da droga traficada pelo acusado, do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 e da regra constitucional prevista no art. 5º, inc. XLIII da Constituição Federal, e de uma política criminal mais rigorosa de repressão aos crimes de tráfico.

Justifico a fixação do regime prisional mais gravoso, a não substituição por pena restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena também pelo fato de estarem ausentes os requisitos dos arts. 44, III, e 77, II, do Código Penal, seja porque o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 estabelece que a reprimenda por crime de tráfico de drogas deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, seja porque o

art. 5º, XLIII, da CF/88, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, destacando também a importância da repressão a esse delito no art. 5º, inc. LI, da Carta Magna.

Frise-se que a Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que as hipóteses excludentes do regime de substituição de penas, contempladas no art. 44 do Código Penal, tem como suporte unicamente o critério do legislador ordinário; já a inconversibilidade das penas quando a condenação decorre do tráfico ilícito de entorpecentes têm por si a vontade do constituinte, que em dois momentos destacou a importância da repressão a esse crime, no art. 5º, XLIII e LI, da CF (Arguição de Inconstitucionalidade/HC 120.353, Corte Especial, Rel. Orig. Min. Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Min. Ari Pargendler, DJe: 18.12.09).

O crime de tráfico de entorpecentes, além de ser equiparado a hediondo e ser a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias de bem. Nesse aspecto, acerca da necessidade do regime mais grave para o tráfico de drogas, cito o voto do eminente Desembargador Machado de Andrade, no julgamento da Apelação nº 0004588-12.2016.8.26.0189, julgado em 21/09/2017:

“Esse desgraçado vício da cocaína chegou em nosso país e, principalmente, nessa cidade de São Paulo, onde todo mundo sabe que existem logradouros públicos, que foram praticamente tomados por viciados. É bom lembrar que o usuário de cocaína quando não tem dinheiro para adquirir a cocaína pura, que é em forma de pó, passa a se utilizar de uma forma inventada nos Estados Unidos, mais, precisamente na cidade de Nova York, no início dos anos 1970, denominada crack, aliás muito mais potente no sentido de fazer com que apenas com uma aspiração da fumaça tóxica (coloca-se a pedra em um pequeno cachimbo, conhecido como “marica”, geralmente de vidro, esquentada-se embaixo com uma chama de isqueiro ou fósforo, e a pessoa suga a fumaça que desprende da pedra de “crack”) já se torna dependente desta desgraça que foi inventada por indivíduos alheios a qualquer sentimento de piedade e que tinham somente interesse em ganhar dinheiro. Ora, uma pessoa que transforma seu semelhante num morto vivo, ou seja, um verdadeiro zumbi, como os que se vê na mídia, principalmente televisiva, indivíduos convivendo juntos na maior sujeira e promiscuidade, sendo que os locais onde essas pobres almas habitam, tem que ser constantemente lavado, com jatos de água e detergentes, pela Prefeitura Municipal, a fim de remover o fedor que exala do chão devido às secreções e excrementos que essas pessoas deixam naqueles locais. Tudo o que disse acima, e que é do conhecimento de todos, acontece por apenas uma razão, devido à ação de pessoas destituídas de qualquer sentimento de amor ao próximo, como é o caso do traficante e, nesses autos, do acusado. Com relação à conduta social do recorrente, não há qualquer dúvida que, com sua atividade de traficantes, ele causou um mal irreparável à sociedade, uma vez que muitos adolescentes, provavelmente, foram por ele jogados no inferno de uma vida de usuário de drogas. O direito, como é cediço, é uma ciência mutável, ou seja, ele tem que acompanhar a evolução humana, e se adaptar às suas necessidades que mudam a cada época do desenvolvimento da sociedade. Assim sendo, como uma das finalidades da pena é intimidar um possível criminoso, é mais do que óbvio que um crime como o tráfico de drogas, que, sem falar nos males causados à pessoa humana, abre as portas para inúmeros outros delitos, como furtos, roubos, homicídios, prostituição etc.; não pode receber um tratamento menos gravoso do que um delito de menor potencial ofensivo. Assim, ante o terrível mal que o réu causava à sociedade antes de ser preso não há outro regime, senão o inicial fechado, como forma de contraprestação do Estado à sua conduta. Fixar-se um regime mais benéfico do que o inicial fechado, seria conceder-se uma benesse ao réu, a qual ele não é merecedor”.

No mais, a concessão dos citados benefícios, além de ser, no meu entender, incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (art. 59 do Código Penal), gerando ofensa ao disposto no art. 44, inc. III, do CP, e verdadeira sensação de impunidade a esta cidade. Por fim, a Lei nº 12.736/2012 deu novas regras ao instituto da detração penal,

prevista no art. 42 do Código Penal, segundo o qual "computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior". Pelo art. 1º: "a detração deverá ser considerada pelo juiz que proferir a sentença condenatória, nos termos desta lei". Já o art. 2º acrescenta o § 2º ao art. 387 do CPP: "o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado